

1500373-37.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... à autoria e a destinação das drogas ao tráfico.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliadas ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico e às circunstâncias da apreensão, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500373-37.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-37.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência 2070503/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 23590546 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 30/22/592

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEGUER RENATO MARQUES SOLLÁ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

GLEGUER RENATO MARQUES SOLLÁ e ADAUTO PEREIRA SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2022, por volta de 14h, na Rua Paschoal Barsottini, nº 100, esquina com a Rua Neusa Maria Mendes, Bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si, traziam consigo e tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 38 (trinta e oito) porções de maconha, pesando cerca de 103,5g (cento e três gramas e cinco decigramas), e 15 (quinze) eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 3,35g (três gramas e trinta e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis estavam em monitoramento velado pelo local dos fatos, quando observaram os acusados em atividade típica de tráfico, eis que ADAUTO acessou um terreno por um buraco existente no alambrado e depois atendeu pessoas na rua, mantendo com elas breve contato, entregando e recebendo algo em troca, ao passo que GLEGUER estava exercendo a função de "olheiro", observando a rua e avisando seu comparsa sobre a aproximação de viaturas policiais. Ante a fundada suspeita, os investigadores procederam à abordagem de ADAUTO, o qual dispensou ao solo um maço de cigarro contendo três porções de maconha e três eppendorfs de cocaína. Na posse desse réu foi apreendida a quantia de R\$ 60,00 em notas diversas. Enquanto ADAUTO estava sendo abordado, GLEGUER saiu caminhando rapidamente, porém foi abordado a um quarteirão de distância do local dos fatos. Na posse dele foi localizada a quantia de R\$ 10,00 em espécie. Indagados, os acusados confessaram informalmente aos policiais a prática delitiva. ADAUTO informou que realizava o tráfico para sustentar seu vício em "crack", ao passo que GLEGUER disse que havia recebido daquele duas porções de cocaína para exercer a função de "olheiro". Ato contínuo, ADAUTO afirmou que no terreno que havia acessado anteriormente havia uma fraílda contendo porções de entorpecentes. Os agentes da lei, então, diligenciaram no local apontado e apreenderam outras trinta e cinco porções de maconha e doze de cocaína, idênticas às que estavam na posse deste réu.

Os réus foram notificados nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06 (fls. 135 e 137) e apresentaram defesa preliminar (fls. 141/145). Após, a decisão de fls. 146/149 recebeu a denúncia e concedeu liberdade provisória para o acusado ADAUTO.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogados os réus.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos réus.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, pela fotografia fls. 35 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 94/96, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os acusados valeram-se do direito de permanecer em silêncio (fls. 04 e 18)

Em juízo, negaram a prática do crime.

ADAUTO disse que ele e Gleguer estavam no local para comprar entorpecentes. Afirmou que comprou trinta reais de cocaína e dez reais de maconha, enquanto Gleguer estava no local para comprar "crack", mas não tinha na biqueira e o traficante saiu para buscar. Disse que o entorpecente encontrado no maço de cigarros que estava em sua posse era seu e para seu uso. Asseverou que, após comprar a droga, permaneceu no local, porque ia comprar duas pedras de "crack" para o Gleguer. Aduziu que sempre fumavam juntos e dividiam a droga. Alegou que eram colegas de droga, mas Gleguer nunca lhe deu droga para usar, pois sempre trabalhou e tinha dinheiro para comprar sua própria droga. Disse que daria a droga para o Gleguer porque ele sempre o acompanhava e moravam perto, não sendo verdade que daria droga para ele ficar como olheiro enquanto traficava.

GLEGUER, a seu turno, afirmou que foi ao local dos fatos com R\$ 10,00 para comprar duas pedras de "crack". Disse que compraria do Adauto, mas ele foi abordado.

Declarou que ele tinha cocaína e maconha e falou que buscaria o "crack". Atestou que, quando viu a abordagem, tentou sair andando, mas também foi abordado. Declarou que já tinha fumado junto com Adauto três ou quatro vezes. Disse que ele dispensou a droga no momento da abordagem. Aduziu que a droga que estava perto do alambrado era do Adauto. Declarou que não estava no local como olheiro e tinha acabado de chegar. Acrescentou que já tinha sido abordado várias vezes pelos policiais, pois, quando era menor, traficava bastante e cumpriu medida na Fundação CASA.

O policial civil Marcelo relatou que recebeu denúncia, no dia dos fatos, dando conta de que uma pessoa com boina marrom e camiseta branca estava traficando num

ponto onde fazem várias prisões. Disse que seguiram para o local, com viatura descaracterizada e observaram Adaauto, com as vestimentas informadas, o qual foi próximo a um terreno e colocou algo por dentro alambrado, vindo a realizar vendas, duas para veículos e outra para motocicleta. Acrescentou que Gleguer, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico, usava camiseta vermelha, e estava olhando o fluxo, dando sinais para Adaauto, provavelmente junto na empreitada. Declarou que abordaram Adaauto, que jogou um maço cigarro com porções de maconha e cocaína, além de dinheiro. Disse que ele confessou que estava traficando porque era viciado em drogas e não tinha como comprar. Aduziu que ele foi questionado e falou que Gleguer estava como olheiro, bem como que deu duas porções para ele para que olhasse. Informou que Gleguer saiu andando rapidamente, mas conseguiram alcançá-lo e ele foi abordado. Afirmou que ele confessou que tinha ganhado duas porções do Adaauto para ficar atuando como olheiro. Informou que Gleguer é usuário, está sempre em biqueiras, sem tomar banho, sem se alimentar, parecendo um zumbi, e já foi abordado duas ou três vezes nessas condições. Disse que, uma semana antes dos fatos, ele foi abordado e deram uma lição de moral nele, dizendo que ele ia se matar daquele jeito. Declarou que os dois réus colaboraram e deu para ver que estavam traficando para poder usar droga, para sustentar o vício. Aduziu que perguntaram a Adaauto o que ele tinha guardado e ele falou que numa fralda, havia 35 porções de maconha e 12 de cocaína, que foram apreendidas.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Bruno, ouvida a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Aliás, o relato dos policiais, no sentido de que os réus informaram que Gleguer receberia duas porções de entorpecentes para ficar no local como olheiro, está em consonância com o que declarou o corréu Adaauto, que admitiu que daria duas pedras de "crack" ao comparsa, não obstante tenha informado que o faria apenas porque eram colegas de droga, o que não é verossímil e não encontrou respaldo nem mesmo na versão do acusado Gleguer.

Enfim, o fato de as policiais terem flagrado os réus juntos, em atividade típica de tráfico, ADAUTO acessando um terreno através de um buraco, depois mantendo contato com pessoas, entregando e recebendo delas algo em troca, enquanto GLEGUER observava a movimentação da rua para avisar o comparsa em caso de eventual aproximação de viaturas, vindo a apreender três porções de maconha e três eppendorfs de cocaína em poder de ADAUTO, além de 35 porções de maconha e 12 porções de cocaína, idênticas às encontradas na sua posse, no do mencionado terreno, conduz à certeza quanto à autoria e a destinação das drogas ao tráfico.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliadas ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico e às circunstâncias da apreensão, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e

forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Acrescento, outrossim, que o fato de os acusados serem usuários de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Impõe-se, portanto, a condenação dos réus como incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Descabe a desclassificação para o crime descrito no artigo 37 do citado diploma legal, pleiteada pela Defensoria Pública em favor do corréu Gleguer.

Ainda que se possa admitir que o réu atuava como "olheiro", tem-se que, nessa função, participava diretamente da própria execução do delito, em divisão de tarefas, figurando, portanto, como coator, o que não se confunde com a conduta prevista no art. 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de "informações".

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. Forense, 8ª ed., pág. 367: "... o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância".

Sobre o tema o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça: "Tráfico de entorpecentes. Agente que exercia a função de "olheiro". Envolvimento não limitado a fornecimento de informação isolada a traficante. Coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes. Desclassificação para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Em se cuidando de agente que exercia a função de "olheiro", ostentando envolvimento não limitado a mero fornecimento de informação isolada a traficante, mas sim verdadeira coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes, não se cogita de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06" (Apelação Criminal nº 1500948-14.2020.8.26.0535, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29.10.20).

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

2.1. ADAUTO PEREIRA DE SOUZA.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado, razão pela qual reduzo a pena de metade, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa.

Não é cabível redução maior em decorrência da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido (103,5g de maconha e 3,3g de cocaína). Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17). Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja "suficiente". Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria. Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.". Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.".

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos". O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, considerando ainda o tempo de prisão cautelar, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

2.2. GLEGUER RENATO MARQUES SOLLA.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é reincidente (processo nº 1500071-13.2019 e processo nº 1500118-84.2019, ambos da 3ª Vara Criminal local - cf. cert. de fls. 118/121). Entretanto, essa circunstância

só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em um sexto, resultando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Ponto que não pode ser reconhecida a atenuante da confissão. Com efeito, a confissão em juízo e perante a autoridade policial justificam a atenuação da pena, mas o mesmo não se pode dizer da confissão informal, que, aliás, também não poderia, por si só, embasar o decreto condenatório. E, no caso em tela, ainda que tenha confessado informalmente a prática do crime aos guardas municipais, o réu valeu-se do direito de permanecer em silêncio quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e, em juízo, negou a prática do delito.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente (fls. 118/121), não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, em regra, é adequado o fechado, em decorrência da reincidência e da natureza do delito, equiparado a hediondo.

No caso dos autos, porém, algumas circunstâncias mitigam essa conclusão: o policial ouvido em audiência atestou que o réu é usuário, está sempre em biqueiras, sem tomar banho, sem se alimentar, parecendo um zumbi, e já foi abordado na mesma situação outras vezes, tanto que já lhe deram lição de moral, dizendo que iria se matar daquela forma; o réu não é reincidente específico - as condenações anteriores decorrem da prática de furto; a quantidade de droga não é exorbitante e o réu já está preso há tempo considerável, mais de oito meses; o corréu Adauto, primário, cuja conduta revela-se mais grave que a de Gleguer (pagaria a este duas pedras de "crack" para atuar como olheiro) já respondeu ao processo em liberdade e teve reconhecido o tráfico privilegiado.

Nesse diapasão, reputo adequada ao caso concreto a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu ADAUTO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixado regime inicial aberto, e GLEGUER RENATO MARQUES SOLLÁ, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixado regime inicial aberto.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.

Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado em favor do corréu Gleguer. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor de ambos os réus, a ser cumprido em regime aberto.

Após trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.I.C.

Piracicaba, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA